

1500539-44.2022.8.26.0575

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: WYLDENSOR MARTINS SOARES

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... Considera que o propósito de praticar tráfico de drogas restou devidamente evidenciado pelas informações recebidas pelos policiais, pela movimentação típica de tráfico de drogas visualizada pelos policiais, pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, pela apreensão e dinheiro e pelo local dos fatos ser ponto conhecido de venda de drogas. Requer o aumento de pena na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

1ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, Sao Jose do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500539-44.2022.8.26.0575 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500539-44.2022.8.26.0575

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2214833/2022 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 26619557 -

DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 2214833 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO RICARDO DA SILVA TONETTI e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WYLDENSOR MARTINS SOARES

Vistos.

Trata-se de ação penal em desfavor de Wellington Felipe Pereira Dutra e Paulo Ricardo da Silva Tonetti, como incurso no artigo 33, caput, c.c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, e com o artigo 29, caput, do Código Penal, eis que no dia 08 de agosto de 2022, por volta das 11h15, na Rua Isidoro Locateli Moreno, altura do nº 36, condomínio São José, neta cidade e comarca, Wellington e

Paulo, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si e com o adolescente Ryan Gabriel Bernarde Ferreira, vendiam e guardavam 03 (três) porções de maconha, pesando 48,09 gramas, 67 (sessenta e sete) invólucros plásticos contendo cocaína, pesando 13,60 gramas, e 12 (doze) porções de crack, pesando 2,40 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Prisão em flagrante dos réus convertida em preventiva na decisão de págs. 63/74.

A denúncia de págs. 119/121 veio amparada no Inquérito Policial – Prisão em Flagrante – de págs. 01/41.

O réu Wellington Felipe Pereira Dutra foi notificado (pág. 157) e apresentou defesa prévia (págs. 161/171) negando a prática do fato. Alega que, no dia e horário dos fatos, não estava no local da diligência policial, mas sim, em sua casa no momento em que ocorreu a abordagem. Aduz que o valor apreendido de R\$ 280,00 lhe pertence e é decorrente de seu recebimento no dia 05, anterior ao fato. Ademais, declara ser usuário de maconha e nesta qualidade esteve no local dos fatos antes da diligência policial. Requer que o denunciado responda ao processo em liberdade.

O réu Paulo Ricardo da Silva Tonetti foi notificado (pág. 183) e apresentou defesa prévia (págs. 149/151), alegando insuficiência de provas.

A denúncia foi recebida aos 21 de setembro de 2022 e foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (págs. 184/186).

Durante referida solenidade foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi procedido ao interrogatório dos acusados, conforme termo acostado aos autos e mídia que se encontra arquivada no SAJ e disponível aos interessados – pgs. 252/254.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal, pois coesos os depoimentos dos policiais e inconvincentes as meras negativas dos réus. Considera que o propósito de praticar tráfico de drogas restou devidamente evidenciado pelas informações recebidas pelos policiais, pela movimentação típica de tráfico de drogas visualizada pelos policiais, pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, pela apreensão de dinheiro e pelo local dos fatos ser ponto conhecido de venda de drogas. Requer o aumento de pena na primeira etapa diante da diversidade de drogas e a consideração da menoridade de Paulo na segunda fase. Indica a majorante capitulada na denúncia, por força do envolvimento de Ryan, adolescente. Os réus ostentam condenações por prática de atos infracionais análogos ao crime de tráfico e não fazem jus à minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Assim, deve ser fixado o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena – pgs. 257/262.

A defesa de Paulo Ricardo alega que sua absolvição é imperativo de justiça, pois o réu negou os fatos e o acervo probatório apenas reúne suposições e não certeza. Alega que os policiais pretendem legitimar suas condutas e seus depoimentos não bastam para a condenação. Invoca o benefício da dúvida. Subsidiariamente, pugna pela minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e reconhecimento da menoridade relativa, convertendo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Os memoriais de pgs. 271/284 se fizeram acompanhar do documento de pgs. 285.

A defesa de Wellington Felipe Pereira Dutra, por sua vez, manifestou-se nas pgs. 286/292 destacando a negativa de autoria. Ressalta a primariedade do réu e seus bons antecedentes, indicando a origem lícita do montante de R\$ 280,00. Alega que não há liame subjetivo entre o réu e o adolescente apreendido. Argumenta acerca da necessidade de dolo para configuração da traficância e que a aquisição de droga

para consumo em conjunto com outra pessoa não autoriza a tipificação na forma do art. 33 da Lei de Drogas. Requer a concessão do privilégio e argumenta que o caso recai sobre "pífias quantidades de drogas que nem mesmo estavam com o réu". Para a defesa "conclui-se que as provas são irrefutáveis no sentido de que o Denunciado não praticou nenhum verbo do tipo penal de tráfico de drogas e sendo assim não é possível penalizá-lo, nem mesmo pelo art. 33 da Lei 11.343/ 06, muito menos pela norma de extensão do art. 29 do Código Penal. Requer a absolvição ou a desclassificação por atipicidade relativa.

DECIDO.

1 -) SÍNTESE PROBATÓRIA

1.1 -) Das provas da materialidade.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão do inquérito policial (págs. 35), documento fotográfico (pág. 36), auto de constatação preliminar (pág. 37), além do laudo pericial (págs. 109/111), que indica que a massa líquida da substância foi de 48,9 + 13,6 + 2,4 gramas, totalizando 64,9 gramas de substâncias entorpecentes diversas, a saber, cocaína, cocaína na forma de crack e maconha.

Houve, pois, modificação do mundo naturalístico pela conduta, restando atendido o princípio da materialização do fato.

2.2 -) Das provas da autoria.

Welther Vaz Martins esclarece que o alvo principal era o Wellington, vulgo "Etô", responsável por distribuir drogas nas biqueiras do bairro, especialmente a da rua 7. O réu compareceu na biqueira um dia, de manhã e manteve contato com Ryan, 3 ou 4 dias antes. Diligenciaram até a rua 7 e viram o "Etô" se aproximando de Ryan de novo e entregou um pacote. O menor foi num terreno, numa árvore e colocou o objeto e "Etô" recebeu algo de Ryan e saiu. Um usuário se aproximou de Ryan e ele indicou para Paulo ir até o local das drogas e entregar droga para um usuário que havia se aproximado. Concluíram que na árvore havia drogas e decidiram abordar. Com o adolescente havia dinheiro. No local onde Paulo foi buscar o invólucro acharam as drogas em quantidade e diversidade. Concluíram que "Etô" tinha levado as drogas e foram para a casa dele. Ele estava chegando com seu veículo e disse que não tinha droga consigo e que havia apenas uma porção de maconha sobre a geladeira que era idêntica àquela encontrada no pé da árvore. No carro dele havia quase R\$ 300,00. Paulo estava traficando sim, mas é conhecido como usuário e acredita que ele recebia pagamento em drogas pelas vendas. "Etô" foi alvo numa operação chamada "Redenção" que teria ocorrido um ano antes da prisão dele. Na ocasião, sabiam que havia uma pessoa chamada "Etô" que levava os kits de drogas, mas naquela época não conseguiram identificá-lo. Ele não deu nenhum esclarecimento e disse que não tinham pego nada com ele, exceto a droga encontrada na geladeira. Ele não justificou o encontro da quantia em dinheiro. Viram o "Etô" fazendo contato com menor em duas ocasiões. O Ryan assumiu que estava traficando, mas não envolveu o seu fornecedor.

A participação do Paulo limitou-se a buscar a droga como descrito. A mercancia ali funciona com dois indivíduos. Um fica na contenção e o outro vai buscar a droga. Geralmente o usuário é quem vai buscar a droga para no caso de flagrante a droga estar com o usuário. Paulo não tinha dinheiro e ele chegou a dizer que não estava traficando não. Na operação anterior, quatro dias antes, Paulo não estava presente. Já sabiam que "Etô" era Wellington antes mesmo da operação que ocorreu 4 dias antes da prisão e já tinham identificado a casa dele. Não abordaram usuários porque o local ali é de intenso fluxo de criminosos e drogaditos e qualquer ação atrapalharia a abordagem ao alvo principal. Acompanharam a situação a uma distância de no máximo 40 metros. Percebeu que o menor entregou alguma coisa para "Etô" e recebeu algo de Ryan. A quantia com Ryan era pequena, menos de R\$ 100,00 e estava em notas fracionadas, assim como o valor encontrado com "Etô" no veículo. A maconha estava sobre a geladeira. Não se recorda de recibos de vendas de roubas. A informação que tinham era que o réu era desocupado. No local há duas residências. Numa delas mora o réu e a companheira.

Evaldo Armando Antonialli relata que tinham denúncias contra Wellington, vulgo "Etô" estaria distribuindo drogas na biqueira da rua 7. Ele já tinha sido investigado na operação "Redenção". Foram ao local, 3 ou 4 dias antes e observaram o Wellington lá que se aproximou do Ryan, menor. Conseguiram observar quando o Wellington entregava algo para Ryan e recebia algo. O menor foi até uma árvore que ficava num pasto, descampado e colocou algo. Um usuário chegou no Ryan, perguntou algo e Paulo Ricardo foi até o local onde Ryan tinha deixado algo e resolveram fazer a abordagem. Com Ryan havia drogas e no esconderijo deles mais drogas, maconha idêntica a que estava com Ryan. Fizeram diligências na casa do "Etô" e ele estava chegando de carro. No veículo encontraram R\$ 280,00 e na casa havia drogas. O "Eto" fazia a recolha do dinheiro. Os réus não falaram nada. Paulo Ricardo na primeira vez não foi avistado no local, mas as informações era de que dois elementos ficavam ali fazendo o tráfico de drogas. Paulo Ricardo disse que era apenas usuário. Fizeram observação a uma distância de uns 25 metros com uso de binóculo. É policial há 25 anos e já fez diversas prisões por tráfico. A residência de Wellington fica a 80 - 100 metros da biqueira. Não chegaram a ver que eles iam até a casa de Wellington. Resolveram ir até a casa de Wellington porque tinham informação de que ele era o gerente. Pode ocorrer revezamento entre os traficantes e no dia da prisão e quatro dias antes o menor estava lá. A quantia em dinheiro não se lembra, mas acha que estavam fracionadas. Com Paulo Ricardo não encontraram nada de ilícito. No primeiro momento, dias antes, Paulo não foi avistado no local. O menor chegou e passou algo para Wellington e recebeu algo. Provavelmente o menor tinha dinheiro na mão. Exceto o que foi apreendido na casa de Wellington, havia com ele uma porção de cocaína e o dinheiro dentro do veículo. Com o menor havia R\$ 50,00. Não se recorda se a quantia estava em notas fracionadas. Não se recorda de ter encontrado recibos sobre vendas de roupas.

O réu Wellington Felipe Pereira Dutra esclarece que foi preso apenas quando era menor. Trabalha de ajudante de pintor e vende roupas. Tem 22 anos, fez agora. Na época do ocorrido tinha 21 anos. Estudou até o terceiro colegial. Tem um filho de dois anos. Usa apenas maconha. Falou com seu advogado antes da audiência. Ouviu o que os policiais disseram e entendeu. Não está correto. Estava em casa às 10 horas. Ia na casa da sua mulher e antes disso foi na biqueira e pegou R\$ 20,00 de maconha. Tinha trabalhado de ajudante de pintor para o Valdeci que tinha lhe pagado na sexta-feira. Ele lhe deu R\$ 300,00. Ficou na casa da sua esposa até meio-dia. Voltou, passou na conveniência, comprou uma coca-cola e foi abordado. A polícia disse que tinha "sortado" o menor, feito contato com ele. Não conhece o menor e nem o Paulo, nunca viu. Falou para o delegado apresentar a filmagem que falaram que tinham e eles não quiseram. A maconha da geladeira tinha acabado de pegar. É usuário e sempre pegou maconha lá. No passado, foi preso sim, mas agora não tem nada a ver com isso. Qualquer esquina no Vale, se for abordado, eles acham que é biqueira. Não foi na biqueira 4 dias antes. Não tem apelido de "Etô". Sua casa fica a uns 100 - 150 metros da biqueira. Conseguia ver o pessoal comprando drogas ali. O

dinheiro tinha trabalhado de ajudante de pintor para o tio da sua esposa o Valdeci. Tinha comprado droga lá há mais de 4 dias e também no dia da abordagem. Sempre pega maconha lá e volta para casa.

O réu Paulo Ricardo da Silva Tonetti nunca foi preso anteriormente. Trabalha na roça. Tem 20 anos. Estudou até o primeiro colegial. Mora com sua mãe. Usa crack todo dia. Já foi internado. A última vez foi em abril desse ano. Não conhece Wellington. Não conhece o Ryan. Ouviu o que os policiais disseram. Tinha descido da sua casa para pegar uma pedra de crack e foi abordado. Eles pegaram e lhe prenderam e depois de 50 minutos prenderam o Wellington. Pegou a pedra de crack com Ryan. Ia efetuar a compra com ele. Não tinha pego ainda. Não tinha dinheiro. Ia no mercado primeiro e pegar dinheiro com sua mãe. Falou com o adolescente se ele podia lhe vender a pedra e pagaria depois. Nisso foi preso. Não pegou nada na árvore e nem entregou para nenhum usuário. Não viu Wellington e nem Ryan antes. Viu apenas quando ele pegou R\$ 20,00 de maconha com o Ryan quando estava descendo ali também. Estava do lado quando ele efetuou a compra. Estava conversando com o menor e o Wellington se aproximou. Estava dentro da viatura quando eles foram na casa de Wellington. Já estava preso. Eles foram na casa dele uns 50 minutos depois. Foi internado duas vezes em clínica.

2 -) DA ANÁLISE CRÍTICA E DO DIREITO APLICÁVEL

Ab initio, é preciso consignar a validade do testemunho policial, pois “goza de presunção de credibilidade”.

Quanto às falas dessas testemunhas, à guisa de ter o agente atuado no feito, tenho por oportuno destacar a sua aproveitabilidade, tanto como a de qualquer pessoa. É que o depoimento do policial, em razão de sua condição de agente da Administração Pública, presume-se verdadeiro e merece crédito, mormente porque se mostra firme, coeso e em consonância com o conjunto probatório dos autos. Tal presunção, obviamente, admitiria prova em contrário, que, entretanto, não foi produzida pela defesa.

A credibilidade do depoimento de policiais tem tanta força quanto a de outros indivíduos. O fato de que cabe a eles a atribuição de prevenir e reprimir o crime não tem o condão de invalidar, de per si, a prova decorrente de seus testemunhos. Por mero preconceito ou suspeita infundada, não deve o Estado-Juiz entender tais depoimentos imprestáveis para lastrear sentença condenatória. O depoimento policial tem plena força probatória, se não houver nenhuma razão plausível, cabalmente comprovada nos autos, para se lhe retirar a credibilidade.

Preceitua o artigo 202 do CPP que “toda pessoa pode ser testemunha”, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob compromisso de dizer a verdade e, assim, sujeitos às penas do crime de falso testemunho. Além disso, desconsiderar a validade probatória de um depoimento levando-se em conta, apenas, a profissão de uma pessoa (por exemplo: policial militar ou civil), nada mais é do que tratamento violador do princípio da igualdade, postura essa temerária ao direito.

O escólio pretoriano bem elucida a questão:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra – tal como ocorre com as demais

testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF – 1ª Turma – HC 74.608-0/SP – Rel. Min. Celso de Mello – DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

“A SIMPLES CONDIÇÃO DE POLICIAL NÃO TORNA A TESTEMUNHA IMPEDIDA OU SUSPEITA – STF, RTJ 68/64 E 168/199” (Damásio E. de Jesus, Código de Processo Penal Anotado, Saraiva, 19ª Edição, 2002, p. 176 e 182).

Ainda nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (...) Ordem denegada.” (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421). (grifos meus)

Outrossim, é de se ter em conta que se tratando de tráfico de entorpecentes, opera-se a “lei do silêncio”, extremamente difícil arrolar testemunhas dispostas a testemunhar contra traficantes.

A perfeita identidade entre as versões, tal como se vê em solo policial e depois em Juízo, é reconhecida pela jurisprudência como fator hábil a dar validade à prova testemunhal policial. Em suas versões, os policiais narraram claramente atos de traficância praticados de forma ajustada entre os réus e o adolescente citado.

Nada faz crer que os policiais estejam agindo imbuídos por sentimentos subalternos dignos de censura tendentes a elucubrar versão incriminadora para aprisionar injustamente pessoas com as quais não mantêm qualquer relação de desafeto comprovada.

Por outro lado, em que pese a presunção de inocência e a possibilidade dogmática de incidência do benefício da dúvida é preciso lembrar que o artigo 156 do Código de Processo Penal é categórico no sentido de que “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

Inexistente contraprova hábil a desqualificar a prova acusatória, o Juízo deve orientar-se pela verdade processual objetivamente existente no processo, sem margem para decisionismo ou dúvida subjetiva. A dúvida deve estar alicerçada na insuficiência de provas ou na existência de provas com versões conflitantes, antagônicas.

Não é possível externar convicção motivada a partir de ilações particulares do julgador, pois a motivação jurídica decorre do processo de persuasão racional, assim entendido como aquele que pode ser devidamente explicado com base nos elementos presentes no processo e não no âmbito psicológico da entidade decidente.

Nesse sentido, os ensinamentos de FRAMARINO DEIMALATESTA, o qual afirma que “o

princípio ontológico coloca o ônus de prova a cargo da acusação, quando considera as duas asserções contrárias, do acusador e acusado, antes da produção de provas. Mas, desde o momento em que o acusador reuniu as suas provas para sustentar a sua asserção, se o acusado, em contradição à asserção do acusador, emite simples asserção contrária, não faz mais que contrapor uma asserção não provada a uma provada e como esta tem direito de ser tomada como verdadeira de preferência a não provada, sendo a presunção da verdade, neste segundo momento, a favor do acusador, a obrigação da prova incumbe ao acusado" (A Lógica das Provas em Matéria Criminal, Campinas: Conan 1995 v. I p. 45-146 destaque do Juízo)

As alegações defensivas de insuficiência de provas não ecoam no espírito deste julgador a ponto de que o fiel da balança incline-se no sentido oposto à pretensão ministerial.

Como sabido, os réus não estão obrigados a produzirem provas contra si mesmos e a negativa em casos desta natureza é natural e esperada. Todavia, insuficiente para evidenciar realidade diversa da que foi exposta com clareza pelos policiais.

A síntese probatória indica que Wellington e Ryan já estavam articulados para a traficância naquela localidade e, no dia dos fatos, receberam o auxílio, ainda que momentâneo, de Paulo Ricardo que dirigiu-se até o esconderijo das drogas para pegar uma porção que seria entregue a comprador.

A origem lícita do dinheiro apreendido não está devidamente esclarecida. A declaração de pgs. 174 apenas indica atividade informar de Wellington junto a Valdecir Donizete de Souza, porém não se refere a qualquer pagamento, datas, valores, de modo que não é hábil a legitimar a origem dos R\$ 280,00 apreendidos com um dos réus (total apreendido de R\$ 330,00).

Note-se nas pgs. 36 que as notas estão fracionadas em cédulas de R\$ 50,00; R\$ 20,00 e até R\$ 5,00, o que fortalece o contexto probatório no sentido da traficância desempenhada pela dupla em ajuste com o adolescente.

A respeito da participação do adolescente a prova testemunhal acusatória é segura em descrever as condutas e a forma pela qual os réus entrosaram-se com o menor, corrompendo-o e prejudicando sua boa formação.

É o que basta para a tipificação da conduta na forma do art. 33 da Lei de Drogas com a majorante do inciso VI do art. 40 da Lei de Drogas.

No que tange à alegada drogadição formulada especialmente pelo réu Paulo Ricardo é sabido que a condição de usuário não é incompatível com a traficância. Noutras palavras, "Ainda que admissível a circunstância de que o réu padeça de toxicomania, a alegação de ser usuário de droga tem-se que em nada modifica a imputação, pois perfeitamente conhecida a figurado viciado-traficante" (STF-2ªTurma, HC-MC73.197/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ22.11.1996).

Sobre a questão já se manifestou a Colenda Corte Paulista: - "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP HC 42.229-3 Rel. Onei Raphael RJTJSP101/498).

Assim, a tese de desclassificação para os moldes do artigo 28 da Lei de Drogas não merece guarida.

Presente a tipicidade delitiva na forma imputada na denúncia e não havendo justificativas ou dirimentes capazes de afastar a antijuridicidade da conduta e culpabilidade dos réus, a condenação é medida necessária para a concretização dos escopos de prevenção geral positiva e prevenção especial colimados pelo sistema

punitivo, além de restabelecer o princípio da prevalência do Direito e atestar a vigência da norma penal violada.

3 -) DO DISPOSITIVO E DOSIMETRIA DA PENA

Ex positis, JULGO PROCEDENTE a denúncia de págs. 119/121, para CONDENAR WELLINGTON FELIPE PEREIRA DUTRA e PAULO RICARDO DA SILVA TONETTI pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, c.c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, e com o artigo 29, caput, do Código Penal, passando a dosar-lhe as penas, nos termos do artigo 68 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas.

Primeiramente em relação ao réu Wellington Felipe Pereira Dutra, analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, observa-se que o modus operandi não recomenda que seja acentuada a pena, pois a culpabilidade é normal à espécie.

O réu é primário - cf. certidão de págs. 46/48.

Poucos elementos foram coletados acerca de sua conduta social e personalidade, razão pela qual não influenciam negativamente a dosimetria. Além disso, deixo transparecer que tais circunstâncias judiciais se analisadas em detrimento do réu evidenciam acolhimento do "direito penal de autor", fenômeno indesejável e antigarantista que não conta com o aval deste Juízo.

Cabe ressaltar, ainda, a exasperação também não é medida a se impor, neste caso, em relação à natureza das drogas. Crack, cocaína e maconha são entorpecentes considerados "comuns" encontrados em qualquer cidade e apreendidos com frequência diária em São José do Rio Pardo.

A interpretação da Lei Penal exige que este Juízo considere que apenas substâncias excepcionais como ópio, LSD, ecstasy, heroína, poderiam justificar a majoração da pena com base na natureza do entorpecente.

No entanto, o critério "quantidade" compreende duas variáveis:

1ª O peso, massa, das substâncias propriamente ditas não recomenda acréscimo, pois a apreensão foi de 64,9 gramas, conforme págs. 109/111.

2ª A diversidade, variedade das substâncias, pois em "quantidade" de drogas podemos ter pequenas ou grandes porções de 1,2,3 ou mais drogas diferentes.

Analisando estes itens o Juízo encontra campo para necessário acréscimo, pois a quantidade-variedade de drogas diferentes (no caso três - cocaína, crack e maconha) impõe aumento de pena, uma vez que o traficante que tem consigo uma variedade de tóxicos está pronto a atender parcela de usuários mais ampla, alcançando "maior clientela" e demonstrando nível superior de periculosidade do que aquele que fornece apenas uma espécie de droga. Assim, deve receber a reprimenda diferenciada em estrita observância ao mandamento constitucional de individualização da pena.

O motivo do delito está albergado na própria tipicidade da traficância enquanto atividade mercantil para obtenção de lucro ilícito.

As circunstâncias do delito não destoam daquelas em que ocorrem crimes desta natureza, ao passo que não há elementos para aferir se as consequências foram graves.

À luz dessas circunstâncias é que fixo a pena-base privativa de liberdade para o

crime capitulado no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, por força da diversidade de entorpecentes, estabelecendo a sanção inicial em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Ausentes agravantes ou atenuantes na segunda fase da dosimetria.

Presente a majorante do inciso VI do art. 40 da Lei de Drogas, hábil a elevar a pena para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Inaplicável a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, conforme certidão de pgs. 46/48 que indica que o réu dedica-se a atividades criminosas desde a menoridade.

A certidão de pgs. 182 aponta que o réu experimentou medida socioeducativa de internação "diante da reiteração do adolescente na prática de ato infracional análogo ao tráfico".

Não se pode perder de vista que somente é ato infracional aquilo previsto como crime. Diz o artigo 103 da Lei 8.069/1990: "Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal." (destaque do Juízo).

Assim, a conduta praticada pelo réu enquanto menor tem natureza criminosa (prevista como crime), porém recebe o tratamento diverso sob a "etiqueta" de ato infracional para os fins da Lei 8.069/1990.

Mas, como a conduta é necessariamente considerada criminosa, sob pena de não poder o menor responder pela prática de ato infracional, soa evidente para este Juízo que a sua prática é suficiente para configuração do óbice "não se dedique às atividades criminosas", previsto no art. 33, § 4º da Lei de Drogas.

No mesmo sentido:

TRF4-) PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. CAUSA DE ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. 1. Incabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, quando demonstrado que o réu praticou diversos atos infracionais, os quais, embora não configurem reincidência ou Maus antecedentes, revelam a dedicação a atividades criminosas, restando ausente um dos requisitos legais necessários à aplicação da referida minorante. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 2. Hipótese em que, conquanto o réu não ostente antecedentes criminais, nem haja prova de que integre organização criminosa, a não aplicação da causa de redução de pena foi fundamentada na existência de mais de 10 (dez) processos instaurados, os quais revelam o histórico de atos infracionais do acusado (estupro, roubo, furto, receptação, lesões corporais, ameaça, tentativa de homicídio e delitos de trânsito), restando evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas e, conseqüentemente, o óbice expressamente previsto na norma legal. (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 5000509-04.2014.404.7210, 4ª Seção do TRF da 4ª Região, Rel. Márcio Antônio Rocha. j. 16.07.2015, maioria, DE 21.07.2015).

E ainda: Apelação Criminal nº 5004789-63.2014.404.7001/PR, 8ª Turma do TRF da 4ª Região, Rel. Simone Barbisan Fortes. j. 30.07.2014, maioria, DE 13.08.2014; Apelação nº 0008236-84.2011.8.08.0024 (024110082369), 1ª Câmara Criminal do TJES, Rel. Ney Batista Coutinho. j. 27.03.2013, unânime, DJ 05.04.2013.

Por sua correção, merece ser prestigiado o ENUNCIADO Nº 32 do FONAJUC: Havendo registro de ato infracional praticado pelo réu, a redução prevista no artigo 33, § 40, da Lei 11.343/06 poderá ser afastada.

Torno em definitiva a pena supra.

A pena de Paulo Ricardo da Silva Tonetti fica igualmente aumentada de 1/6 na primeira fase diante da diversidade de drogas, resultando 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria reconduzo a pena ao mínimo de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, diante da menoridade relativa.

Presente a majorante do inciso VI do art. 40 da Lei de Drogas que eleva a pena novamente para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Inaplicável, outrossim, a minorante do § 4º do art. 33 da lei de drogas, diante da certidão de pgs. 42 que indica que o réu, a exemplo de Wellington, também dedica-se a atividades criminosas desde a menoridade. Reporto-me aos fundamentos expostos na dosimetria do corréu a respeito.

Destaque-se nas pgs. 208 a imposição de medida de internação.

Torno em definitiva e pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Mantido o caráter hediondo da conduta, a pena de ambos os réus deverá iniciar-se em regime FECHADO, pois apenas este regime é capaz de desvinculá-los da "teia criminosa" em que estão inseridos. O retorno precoce ao meio aberto deixaria os réus expostos a fornecedores de maior envergadura e à antiga "clienteia" o que constitui forte estímulo para a reincidência e persistência de violação da ordem pública.

Como se nota, ambos os réus experimentaram medidas sócio-educativas de internação e não se emendaram, de modo que regimes menos contundentes afiguram-se claramente insuficientes para introjetar-lhes os valores necessários à ressocialização.

NÃO PERMITO que os réus recorram em liberdade, ratificando os fundamentos de pgs. 63/74, especialmente o enunciado 34 do FONAJUC, citado nas pgs. 72, assim como os fundamentos de pgs. 239/242.

Recomendem-se no estabelecimento prisional em que se encontram, pois as custódias doravante passam a alicerçar-se na presente sentença penal condenatória recorrível.

Nos termos dos artigos 804 e 805 do CPP, CONDENO os réus ao pagamento das custas processuais que fixo em 100 UFESP's. Saliento que "A condição de beneficiário da Justiça Gratuita não isenta o condenado do pagamento das custas. Eventual isenção poderá ser avaliada à época da execução da sentença condenatória, quando serão apreciadas as reais condições quanto ao estado de pobreza do réu e à possibilidade do pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Precedentes. Recurso desprovido, nos termos do voto do relator" (STJ, REsp 343.689/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, T5, DJ 22.04.03, p. 253).

O (in) deferimento de AJG poderá ser apreciado em fase de execução.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências:

Expeçam-se as guias de execução definitivas;

Proceda-se ao recolhimento dos valores atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686 do Código de Processo Penal;
Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, § 2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República;
Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias;
Decreto o perdimento dos valores apreendidos, pois à míngua de comprovação de origem lícita estão claramente vinculados à mercancia de entorpecentes ilegal desempenhada pelos réus.
Nos termos do art. 72 da Lei de Drogas, proceda-se à destruição do entorpecente mantido para fins de contraprova.

P.I.C.

Sao Jose do Rio Pardo, 31 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA